

1500969-21.2019.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: Thiago Baldani Gomes De Filippo

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital

Data de Disponibilização: 17/11/2022

... prisão de VINICIUS e colheu anotações relacionadas ao tráfico de drogas na residência da esposa de WILLIAN, informou que abordou ANTONY, que até então desconhecia, quando transitava em uma motocicleta na região de Taipas. Ao ser questionado sobre sua suposta participação no "tribunal do crime", apresentou nervosismo, o que motivou a sua condução à unidade policial, quando foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Capital

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500969-21.2019.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500969-21.2019.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Qualificado (Crime Tentado)

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 1495/2019 - 72º D.P.

VILA PENTEADO, 2071734/2019 - 72º D.P. VILA PENTEADO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VINICIUS FELIPE ALVES FEDELES e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Thiago Baldani Gomes De Filippo

Vistos.

1.VINICIUS FELIPE ALVES FEDELES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 15 da Lei 10.826/2003, nos arts. 329, § 1o, e 148, § 2o, ambos do Código Penal, e no art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013; e JOSÉ GABRIEL GOMES, WILLIAM NASCIMENTO SAMPAIO, ANTONY RICARDO MADEIRA DOS SANTOS MARIANO e VALDECI DA SILVA, também qualificados nos autos, foram denunciados como incursos no art. 148, § 2o, do CP, e no art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013, pelos seguintes fatos: (a) no dia 10 de março de 2019, por volta de 16h30min, na Rua Fragata da Constituição, altura no número 135, Jaraguá, Município de São Paulo, VINICIUS teria efetuado disparos de arma de fogo em via pública e se oposto à execução de ato legal mediante violência

contra funcionário competente para executá-lo; (b) em data anterior e até o dia 10 de março de 2019, em horário e local ignorados, no Município de São Paulo, VINICIUS, JOSÉ GABRIEL, WILLIAM, ANTONY e VALDECI teriam integrado, juntamente com inúmeros outros indivíduos, a organização transnacional conhecida como "Primeiro Comando da Capital" (PCC), estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter, direta e indiretamente, vantagem ilícita mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a quatro anos, havendo, na sua atuação, emprego de arma de fogo; (c) desde a madrugada do dia 8 de março até as 16h30min do dia 10 de março de 2019, em diferentes endereços da Zona Norte do Município de São Paulo, VINICIUS, JOSÉ GABRIEL, WILLIAM, ANTONY e VALDECI teriam privado Douglas da Silva Moreira de sua liberdade, mediante cárcere privado, tendo resultado a essa vítima, em razão de maus tratos e da natureza da detenção, grave sofrimento físico e moral.

Recebida a denúncia (fls. 95/99), os réus foram citados (fls. 154, 155, 218, 523 e 541) e apresentaram respostas à acusação (fls. 612/614 e fls. 632/650). Rejeitadas estas, ratificou-se o recebimento da denúncia (fls. 1178/1180).

Durante a instrução, foram colhidas as declarações das quatro vítimas e ouvidas cinco testemunhas. Os réus foram interrogados (fls. 1755/1756 e 1805/1809).

Ao cabo, após a apresentação dos memoriais (fls. 1854/1860, 1865/1872, 1885/1897 e 1898/1920), o MM. Juízo da 2ª Vara do Júri houve por bem desclassificar o delito, afastando-se, por consequência, a competência do tribunal do júri (fls. 1921/1935).

Operada a redistribuição a esta vara especializada, nos termos da Res. OE/TJSP 811/2019 (fls. 2048/2050), houve novo aditamento à denúncia (fls. 2145/2148) e, após a manifestação dos acusados (fls. 2167/2172, 2175/2180, 2201/2205, 2214/2215 e 2394/2404), contou com o recebimento por parte deste juízo (fls. 2412/2415).

Os acusados foram novamente interrogados (fls. 2476/2478). Ao cabo, o Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia (fls. 2482/2496), ao passo que as Defesas, em síntese, pleitearam as respectivas absolvições, por insuficiência de provas, destacando a Defesa de VINICIUS, em sede preliminar, a declaração da nulidade absoluta do reconhecimento fotográfico, pela ausência de cumprimento dos requisitos do art. 226 do Código de Processo Penal (fls. 2541/2547, 2548/2553, 2554/2570, 2578/2607 e 2608/2621).

É o relatório.

2. Eis o relato dos fatos, tal como versado pela exordial acusatória, considerados os aditamentos realizados:

Em meio às atividades criminosas desenvolvidas [pela] organização criminosa, foi deliberada a instauração de uma espécie de "tribunal do crime", com a finalidade de fazer justiça com as próprias mãos, sendo determinado que os indiciados, além de outras pessoas, dele participassem.

Para tanto, na madrugada do dia 08 de março deste ano, estando a vítima no interior de um bar localizado em uma travessa da Avenida Deputado Cantídio Sampaio, próximo ao Parque de Taipas, foi ela abordada por um indivíduo conhecido pelo vulgo "irmão cara de peixe", que, apontando-lhe um revólver, disse-lhe que aquele local era dos irmãos do PCC e passou a acusá-la de ter cobrado para realizar ligações clandestinas de água na favela da Capadócia, sem a autorização do PCC. Assim, Douglas foi sequestrado e colocado no interior do veículo VW Fox, de cor vermelha, juntamente com outros indivíduos, entre eles "cara de peixe", sendo levado à favela da Capadócia, onde foi amarrado e colocado em um barraco, para a realização do mencionado "tribunal do crime". Ficou nesse barraco por um dia, onde foi espancado, dentre outros integrantes da organização criminosa, pelo indiciado JOSÉ GABRIEL, que dele tirava fotos e as mandava para demais integrantes do PCC. Posteriormente, foi levado para uma residência no Jardim Brasília, em Parada de Taipas, onde permaneceu por dois dias, sempre sob ameaças de morte, com emprego de arma de fogo, e agressões. Em seguida, foi a vítima levada novamente para a Capadócia, para outro barraco, onde estava o "irmão cara de peixe", tendo nesse local chegado os integrantes do PCC conhecidos pelos vulgos de Marccone, Cauã, "irmão Pirata" e "irmão zoio", entre outros, sendo que nesse local foi espancada e avisada que seria levada dali para o local onde seria morta.

No dia 10 de março de 2019, os criminosos amarraram a vítima, com fios nos pulsos e

no tórax, e a retiraram do cárcere, colocando-a no veículo VW Fox Vermelho, de placa DON-7729, que era dirigido por JOSÉ GABRIEL, estando em seu interior, também, o indicado VINICIUS, que esteve nos locais em que a vítima era mantida em cárcere privado, tendo-a agredido também. No trajeto até o local em que a executariam, cruzaram com uma viatura da Polícia Militar, ocasião em que a vítima passou a gritar por socorro, tendo a equipe policial passado a realizar acompanhamento ao veículo Fox, que se evadiu da viatura em alta velocidade, vindo a colidir com o veículo GM Monza, de placa CHX-8033, e, na sequência, teve um de seus pneus dianteiros estourado, após passar por uma lombada, quando VINICIUS e outro integrante do PCC, ainda não identificado, saíram pela porta direita dianteira, tendo VINICIUS efetuado disparo de arma de fogo em via pública para o fim de se opor à prisão que seria realizada pelos policiais.

Na sequência, o motorista da viatura, CB PM Gonzaga, efetuou dois disparos na direção de VINICIUS, tendo um dos disparos atingido o veículo Fiat Palio de placa CSA-1288. O auxiliar da equipe, SD PM Martins, efetuou um disparo na direção de VINICIUS, não sendo possível visualizar se alguns desses disparos o atingiram, tendo em vista que o mesmo se evadiu em direção a uma viela.

Diante da atuação desses policiais militares, a vítima foi resgatada do interior do veículo VW Fox, onde foi encontrada amarrada.

O denunciado WILLIAM NASCIMENTO SAMPAIO, que também estava no interior do cativado onde a vítima foi mantida em cárcere privado e participou das agressões contra ela, tendo nela desferido socos, pontapés e pauladas, realizava a escolta do veículo VW Fox que a levava para a morte, no veículo Fiat Palio, de placa DDS-4820, por ele dirigido, que dava suporte ao mencionado VW Fox.

O indicado ANTONY RICARDO MADEIRA DOS SANTOS MARIANO estava no interior do cativado da vítima, sendo o responsável por conduzir as deliberações do "tribunal do crime", tendo voz ativa sobre as deliberações, tendo transmitido aos demais criminosos a determinação para matar Douglas, sendo ele, então, colocado no interior do Fox vermelho para ser levado ao local onde seria executado.

O denunciado VALDECI DA SILVA, que era "disciplina" da organização criminosa descrita no bairro do Jaçanã, na Zona Norte desta Capital, esteve no cativado da vítima e foi uma das pessoas responsáveis por determinar a ordem de execução dela à morte, sendo ela, então, colocada no interior do Fox vermelho para ser levada ao local onde seria morta.

(...)

Dessa forma, o disparo efetuado nos policiais militares, com o objetivo de alvejar qualquer um deles, tinha por finalidade assegurar a impunidade do crime de cárcere privado de que era vítima Douglas da Silva Moreira.

A ação penal procede em parte.

2.1.Com efeito, no que toca à imputação referente ao delito de cárcere privado e de integrar organização criminosa, a robustez dos elementos probatórios coligidos converge para o seguro acolhimento da pretensão acusatória relativamente a JOSÉ GABRIEL e VINICIUS, impondo-se a absolvição em relação aos demais acusados.

A materialidade do crime de cárcere privado, aliás, está circunstanciada pelo laudo de lesão corporal (fl. 196) e as autorias de ambos os réus são cristalinas. Nesse sentido, a vítima Douglas da Silva Moreira confirmou a essência da descrição fática, dizendo que, na data dos fatos, encontrava-se em uma "balada", quando foi abordado por "Bibi" e por "Cara de Peixe" e, em seguida, por diversos outros indivíduos. Um deles apontou um revólver contra si, quando, então, deu um tapa na arma. Disse ter sido sequestrado e conduzido para a Capadócia, local em que permaneceu por quatro dias. Em seguida, foi levado ao Jardim Brasília, onde permaneceu outros dois dias, quando foi novamente encaminhado à Capadócia. Neste local, ouviu quando indivíduos discutiam sobre o seu destino, se deveriam agredi-lo ou matá-lo. Foi novamente colocado em um veículo e guiado para Taipas. No percurso, ao notar a presença de uma viatura policial, a partir de uma brecha no vidro, a vítima disse ter gritado por socorro. Então, a viatura começou a perseguir o veículo, que chegou a abalroar diversos outros, ao alcançar uma rua sem saída. Os policiais conseguiram, então, abordar o motorista e os demais fugiram. Estes passaram a trocar tiros com os policiais. VINICIUS foi atingido com um tiro no

braço. "Irmão zoio" conseguiu fugir. Esclareceu que WILLIAN estava no cativado e realizava a escolta do veículo em que a vítima estava sendo transportada. Também aduziu que ANTONY, conhecido como "irmão Tony" era outro que se encontrava no cativado e conduzia as tomadas de decisões do "tribunal do crime", transmitindo aos demais as determinações de outros membros do PCC, incluindo a deliberação sobre sua morte. Afirmou, outrossim, que VALDECI era "disciplina" do PCC do Jaçanã e participou das discussões em torno de sua execução. Os motivos do crime foram inicialmente apontados pela vítima pelo fato de ter cobrado uma "taxa" dos moradores da comunidade, relativa ao custo de uma mangueira que providenciou para levar água aos barracos, sem autorização do PCC, porém, ao final, também foi acusado falsamente de ter praticado "indecências com menores", o que foi determinante para a decisão a respeito de sua morte (fls. 1755/1756). Em audiência, a vítima reconheceu todos os acusados e detalhou as condutas de cada qual (fls. 1805/1809).

A versão da vítima, relativamente ao acionamento da viatura policial e de seus desdobramentos, foi confirmada pelos policiais militares Rodolfo Stefano Marinelli de Oliveira, Cássio Martins Rodrigues e Reginaldo Gonzaga dos Santos, que tomaram parte na ocorrência e também seguramente reconheceram JOSÉ GABRIEL como motorista do veículo que conduzia a vítima, além de apontar, com certa margem de insegurança, VINICIUS como o sujeito que possivelmente estaria armado e teria efetuado disparo contra os agentes públicos.

O delegado de Polícia Luiz Coelho Júnior obtemperou, de relevante, que a vítima reconheceu os investigados como autores do fato, ao passo que o também delegado de Polícia Bruno Guilherme de Jesus apresentou detalhes acerca da rápida descoberta de VINICIUS, que havia dado entrada em um hospital de Praia Grande/SP por causa de ferimento causado por arma de fogo, poucas horas depois do ocorrido, quando, então, foi reconhecido pelo ofendido.

Por seu turno, o delegado de Polícia Bruno Guilherme de Jesus, responsável pela lavratura da prisão em flagrante de JOSÉ GABRIEL e, posteriormente, de VINICIUS, confirmou a troca de tiros e o reconhecimento e a localização deste último em uma unidade hospitalar, horas depois dos fatos, quando foi reconhecido pela vítima. Já o policial civil Flávio André Luis de Campos esclareceu que tomou parte em algumas diligências da fase preliminar investigativa, tanto aquelas que culminaram com a prisão de VINICIUS, quanto da indicada colheita de indícios da participação de WILLIAN, a partir de buscas realizadas na residência da esposa dele.

Em semelhante sentido no que toca à participação de WILLIAN, o policial militar Leonardo Bezerra dos Santos afirmou que, a par das características indicadas pela vítima a respeito da utilização de um veículo Pálio na cena do crime, logrou encontrar automóvel com descrições semelhantes e o seu condutor foi conduzido à unidade policial, quando foi reconhecido pela vítima como um dos participantes de seu sequestro.

E, por fim, o policial civil Francismar Pedro dos Santos, após indicar que também participou da localização e prisão de VINICIUS e colheu anotações relacionadas ao tráfico de drogas na residência da esposa de WILLIAN, informou que abordou ANTONY, que até então desconhecia, quando transitava em uma motocicleta na região de Taipas. Ao ser questionado sobre sua suposta participação no "tribunal do crime", apresentou nervosismo, o que motivou a sua condução à unidade policial, quando foi reconhecido pela vítima. O policial obtemperou, ao cabo, que, durante a abordagem, ANTONY admitiu que era conhecido como "irmão Tony" e que integrava o PCC.

Em suas autodefesas, todos os acusados negaram o envolvimento com os fatos criminosos (fls. 2476/2478). JOSÉ GABRIEL, embora tivesse admitido que conduzia o veículo abordado pela Polícia, disse que somente o fazia atendendo pedido de seu vizinho "Joãozinho", para que conduzisse terceira pessoa ao hospital. Somente após os disparos dos policiais é que tomou conhecimento que o sujeito que ocupava o assento traseiro estava em "situação de cárcere". VINICIUS, por sua vez, esclareceu que, após discutir com a esposa, dirigiu-se ao litoral, quando, à beira mar, foi vítima de assalto e acabou sofrendo ferimentos decorrentes de um disparo de arma de fogo, razão pela qual buscou atendimento médico. Quando se encontrava no hospital, foi visitado por policiais e fotografado. No terceiro dia de internação, recebeu

voz de prisão em flagrante por um crime que não cometeu. Obtemperou que, apesar de residir na Zona Norte da Capital e conhecer a localização da Capadocia, não a frequentava, porque sua rotina em diversas localidades. WILLIAN, ANTONY e VALDECI, cada qual ao seu modo, negaram peremptoriamente qualquer participação nos fatos criminosos e suposto pertencimento ao PCC.

Pois bem. É de se sublinhar, em primeiro lugar, que o reconhecimento fotográfico de VINICIUS (fls. 25/26) e o próprio reconhecimento pessoal dos acusados (fl. 1807) desatendeu aos comandos estabelecidos pelos art. 226 e seguintes do CPP, sob pena de nulidade. Entretanto, embora titubeante até há pouco tempo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça atualmente se solidificou no sentido da necessária observância do procedimento descrito pela lei processual penal, sob a pena de nulidade. Eis a seguinte transcrição do acórdão paradigma:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciários de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, conseqüentemente, de graves injustiças.

6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com

destaque para a "defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis" (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de "zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (art. 129, II).

(...)

12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

(...)

Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação." (STJ, HC 598.886/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020).

Referida decisão deve ser obrigatoriamente observada pelos demais juízos e tribunais, sob a pena de nulidade das decisões que não o fizerem, nos termos do art. 315, § 2º, VI, do CPP, com redação determinada pela Lei 13.964/2019, que reputa como não fundamentada qualquer decisão judicial que deixa de seguir "enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento".

Destarte, a previsibilidade das decisões judiciais é instrumento harmonizador dos princípios da segurança jurídica e da própria isonomia e deve ser buscada na maior medida possível, pela observância às posições jurisprudenciais consolidadas, em especial pelos Tribunais Superiores, porque a tais Cortes se tem atribuído modernamente a função de unificação do Direito. As exceções, consoante o próprio texto legal, ficam por conta da distinção do caso (*distinguishing*), diante das vicissitudes fático-jurídicas do caso concreto; ou superação do entendimento (*overruling*), quando a decisão invocada já não é mais a posição da Corte que a havia apresentado.

Os reconhecimentos levados a efeito são, portanto, inválidos, por malferir o devido procedimento veiculado pelos artigos 226 e seguintes do CPP, conduzindo-se à absolvição dos acusados, à exceção de JOSÉ GABRIEL e VINICIUS, para quem deve ser operado o *distinguishing*, já que o reconhecimento fotográfico e pessoal de VINICIUS e o reconhecimento pessoal de JOSÉ GABRIEL não são os únicos elementos que podem ser utilizados para a demonstração das autorias.

Com efeito, JOSÉ GABRIEL foi preso em flagrante, tendo sido surpreendido pelos policiais ainda no interior do veículo que conduzia a vítima, não se apresentando minimamente crível a versão veiculada por sua autodefesa, sequer havendo indicações a respeito da identidade hipotética de seu vizinho "Joãozinho", que supostamente lhe solicitara uma carona.

VINICIUS, por sua vez, foi localizado horas depois, quando havia dado entrada em estabelecimento hospitalar em razão de ferimento causado por disparo de arma de fogo. A versão de seu interrogatório igualmente não se mostra convincente, porque

sequer há indícios de que havia sido vítima de um crime de roubo no litoral, sendo perfeitamente exigível o registro policial da ocorrência.

Em relação a JOSÉ GABRIEL e VINÍCIUS, portanto, em que pese a nulidade do reconhecimento, há elementos bastantes o acolhimento da pretensão. Nessa direção, aliás, recentemente, o STJ, apesar de salientar as conclusões do citado acórdão paradigma, também aplicou o distinguishing para caso análogo ao presente, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. DELITOS DE ESPÉCIES DISTINTAS. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR MANTIDA. SÚMULA 500/STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

2. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. No caso dos autos, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishingem relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois a autoria, no caso, resta fartamente demonstrada a autoria delitiva por diversas provas – depoimento de testemunha que teria recebido mercadoria comprada com o cartão de crédito da vítima, registro de câmeras de vídeo e login em rede social e em nome do paciente, em um dos celulares roubados –, assim como pelo reconhecimento uníssono das vítimas em juízo (...) (STJ, AgRg no HC 765.098/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022) – grifei.

Portanto, a desconsideração dos reconhecimentos fotográfico e pessoais não conduz, automaticamente, ao descolhimento integral da pretensão acusatória, se houver outros elementos capazes de ensejar a condenação, circunstância verificada, no caso dos autos, para JOSÉ GABRIEL e VINÍCIUS, que permitem concluir a respeito da prática, por ambos, tanto do crime de cárcere privado, quanto do delito de integrar organização criminosa.

Quanto a este último delito, as declarações da vítima, aliadas aos depoimentos das testemunhas, são robustas o suficiente para se compreender que o crime de cárcere privado foi praticado no contexto de um denominado "tribunal do crime", provavelmente como etapa preparatória à execução da pena de morte, à qual já tinha sido "sentenciado" o ofendido. O significativo lapso temporal do cárcere, aliado à diversidade de indivíduos e à própria menção de seus integrantes de pertencimento ao PCC, tal como declarado pela vítima, permite a colmatação do tipo penal correspondente.

A mesma conclusão não se opera em relação aos outros três corréus. WILLIAN ocuparia um veículo Palio que escoltaria o veículo que conduzia a vítima, mas sequer há segurança de que se trata do mesmo automóvel, à míngua de seu reconhecimento. No que toca a ANTONY e VALDECI a inexistência de elementos outros que não o reconhecimento é ainda mais evidente. Não há elementos para se concluir a respeito dos motivos que teriam conduzido o policial civil Francismar Pedro dos Santos a concluir pela participação da ANTONY, cujo nome sequer havia sido ventilado pela vítima em solo policial. E, por fim, em relação a VALDECI, desconsiderado o reconhecimento, também não há qualquer outro elemento que possa indicar, sequer remotamente, sua participação nos fatos, inexistindo outro caminho, que não as respectivas absolvições.

2.2.E, relativamente às imputações de disparo de arma de fogo e resistência direcionadas a VINICIUS, as provas indicam seguramente que ele efetuou o disparo de arma de fogo em via pública para o fim de se opor à prisão que seria realizada pelos policiais, como, aliás, indicado repetidamente pelo teor da prova oral, Entretanto, observada a dimensão material do ne bis in idem intrassistêmico, do mesmo fato não devem derivar as duas pretendidas imputações, em razão das almejadas unidade e coerência do sistema jurídico-penal, atendendo-se a critérios lógicos e de valoração jurídica do fato.

Em que pese a ausência de previsão legal expressa, o aparente concurso de normas deve ser resolvido pelo critério da subsidiariedade ("lex primaria derogat legi subsidiariae"), que se opera "quando uma norma que define crime menos grave está abrangida pela norma que define o crime mais grave, nas circunstâncias concretas em que o fato ocorreu." Na hipótese dos autos, portanto, cotejados os respectivos preceitos penais secundários, prevalece a norma definidora do crime mais grave, a saber, o tipo do art. 15 da Lei 10.826/2003.

Sublinhe-se, apenas por dever de argumentação, que referido tipo penal pode transmitir a falsa ideia de que seria, em qualquer situação, expressamente subsidiário, por conter a cláusula de reserva "desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime". Ocorre que, apesar da reticência legal, naturalmente que a ratio legis demanda a prevalência de outra norma penal desde que retrate crime mais grave, desapegando-se de sua interpretação literal, em atenção à própria essência do critério da subsidiariedade. Aliás, é o que nitidamente se observa da leitura do tipo de perigo para a vida ou saúde de outrem (art. 132 do CP: "(...) Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, se o fato não constitui crime mais grave") e do tipo de falsa identidade (art. 307 do CP: "(...) Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave").

Destarte, confrontando-se ambos os preceitos penais secundários, à luz dos fatos concretos, o tipo do art. 15 da Lei 10.826/2003 é norma primária sobre a norma subsidiária do art. 329, § 10, do CP.

2.3.Com isso, VINÍCIUS e JOSÉ GABRIEL praticaram fatos típicos, ilícitos e culpáveis, impondo-se as respectivas condenações. Passa-se à dosimetria das penas.

2.3.1.VINICIUS:

2.3.1.1. Crime de disparo de arma de fogo: na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, observa-se que o réu apresenta mau antecedente (Feito 0091047-22.2011.826.0050, 8a Vara Criminal da Capital, fl. 113), ensejando o aumento da pena em mais 1/6, observando-se, quanto aos demais registros criminais, o teor da Súmula 444 do STJ e à tese de repercussão geral fixada pelo STF no julgamento do RE 591.054/2004. Na segunda etapa, delinea-se a agravante da reincidência (Feito 0012697-78.2015.826.0050, 5a Vara Criminal da Capital, fl. 113), implicando o aumento da pena em mais 1/6. Quanto ao reconhecimento da reincidência, é desnecessária a existência de certidão cartorária, bastando que a informação a respeito do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e da data do término de cumprimento ou de extinção da pena venham devidamente explicitadas na respectiva folha de antecedentes, nos termos da Súmula 636 do STJ. Por outro lado, também se delinea a agravante do art. 61, II, b, do CP, na medida em que o disparo tinha por finalidade assegurar a impunidade do crime de cárcere privado, acarretando a elevação da pena em mais 1/6. Inexistem atenuantes. Na terceira etapa, não há causas de aumento e de diminuição de pena. Com essas considerações, fixo ao acusado a pena de 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa.

2.3.1.2. Crime de cárcere privado: na primeira etapa, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, houve o incremento da culpabilidade, assim entendida como o grau de juízo de reprovação social do comportamento, pelo excepcional desvalor da conduta, representado pelas circunstâncias do crime, já que a vítima, segundo suas declarações, foi mantida em cárcere por 6 dias, lapso bem superior ao tempo exigível para a configuração do tipo penal, que se diferencia do mero constrangimento ilegal (art. 146 do CP) pela exigência de algum prolongamento temporal da conduta, ainda que breve. Assim, elevo a pena em 1/6. Por sua vez, o

elevado desvalor do resultado, reverberado nas lesões corporais sofridas pela vítima (fl. 196), já é apto a qualificar o crime e não será considerado para elevar a pena-base, para que não haja bis in idem. Ainda na primeira etapa, a circunstância de o réu ser portador de mau antecedente (Feito 0091047-22.2011.826.0050, 8a Vara Criminal da Capital, fl. 113) implica o aumento da pena em 1/6. Na segunda fase, positiva-se a agravante da reincidência (Feito 0012697-78.2015.826.0050, 5a Vara Criminal da Capital, fl. 113), ocorrendo o aumento em mais 1/6. Inexistem atenuantes. Na terceira etapa, não se vislumbram causas de aumento e de diminuição de pena. A partir dessas premissas, fixo ao réu a pena de 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão.

2.3.1.3. Crime de participação em organização criminosa: na primeira etapa, assim como apontado para os delitos acima, o mau antecedente ostentado pelo réu implica a elevação da pena em 1/6. As demais circunstâncias judiciais não conduzem à exasperação da pena. Na segunda fase, delinea-se a agravante da reincidência, positivando-se outro aumento de 1/6. Não há atenuantes. Na terceira etapa, delinea-se a causa especial de aumento de pena prevista no § 2o do art. 2o da Lei 12.850/2013, consistente no emprego de arma e fogo. Como se tratou de uma única arma, elevo a pena em somente 1/6. Não há causas de diminuição de pena. Assim, fixo ao réu a pena de 4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão, além do pagamento de 14 dias-multa.

2.3.1.4. Concurso material: impõe-se o reconhecimento do cúmulo material, contemplado pelo art. 69 do CP, somando-se as penas, o que redundará na fixação de 11 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão, além do pagamento de 28 dias-multa, no mínimo legal, à míngua de indicações seguras acerca da capacidade econômica do acusado. O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do art. 33, § 2o, a, do CP, não se cogitando da progressão antecipada de regime de que trata o art. 387, § 2o, do CPP, porque entre a data da prisão do réu e a presente data não transcorreu prazo superior a 3/5 da pena ora aplicada, em atenção ao disposto no art. 2o, § 2o, da Lei 8.072/1990, em vigor na data do fato e dotada de ultratividade, por ser mais benéfica do que os critérios atualmente estabelecidos para a progressão de regime pelo art. 112 da Lei 7.210/1984, com redação determinada pela Lei 13.964/2019.

2.3.2. JOSÉ GABRIEL:

2.3.2.1. Crime de cárcere privado: na primeira etapa, em atenção às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, pelos mesmos motivos expostos em relação ao corréu, relativamente ao incremento do desvalor da conduta, elevo a pena em 1/6. Ainda na primeira etapa, observa-se que os registros criminais existentes em desfavor do acusado (fls. 115/117) não conduzem à exasperação da pena, em atenção à Súmula 444 do STJ e à tese de repercussão geral fixada pelo STF no julgamento do RE 591.054/2004. Na segunda etapa, não há agravantes e atenuantes e, na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena. Com isso, fixo ao réu a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão.

2.3.2.2. Crime de participação em organização criminosa: na primeira fase, não há razão para a elevação da pena-base. Na segunda etapa, inexistem agravantes e atenuantes. Na terceira, delinea-se a causa especial de aumento de pena consistente no emprego de arma de fogo e, na medida utilizada em relação ao corréu, elevo a sanção em 1/6. Não há causas de diminuição de pena. Com isso, fixo ao réu a pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa.

2.3.2.3. Concurso material: verificado o cúmulo material, a teor do art. 59 do CP, as penas devem ser somadas, redundando no total de 5 anos e 10 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal, à míngua de indicações seguras acerca da capacidade econômica do acusado.

Independentemente da primariedade e do patamar da pena fixada, o regime inicial de cumprimento de pena seria o fechado, nos termos do art. 33, § 3o, do CP, por serem as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado. Entretanto, ele já se encontra preso desde 11/03/2019 (fls. 02/03), transpondo-se, com isso, mais de 2/5 da pena ora imposta, de maneira que o réu faz jus à chamada progressão antecipada de regime, contemplada pelo art. 387, § 2o, do CPP. Assim como ponderado em relação ao corréu, o patamar de 2/5, veiculado pela art. 2o, § 2o, da Lei 8.072/1990, é

mais favorável do que as diretrizes ora estabelecidas pelo art. 112 da Lei 7.210/1984, com redação determinada pela Lei 13.964/2019, que se consubstancia em novatio legis in pejus, insuscetível, portanto, de retroatividade. Assim, fixo-lhe o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, b, do CP.

3. Em face do exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para: (1) condenar VINICIUS FELIPE ALVES FEDELES, qualificado nos autos, no cumprimento de 11 anos, 1 mês e 11 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 28 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao art. 15 da Lei 10.826/2003; ao art. 148, § 2o, do Código Penal; e ao art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013; todos na forma do art. 69 do Código Penal; (2) condenar JOSÉ GABRIEL GOMES, qualificado nos autos, no cumprimento de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo o valor de cada dia, por infração ao art. 148, § 2o, do Código Penal; e ao art. 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013; todos na forma do art. 69 do Código Penal; e (3) absolver WILLIAM NASCIMENTO SAMPAIO, ANTONY RICARDO MADEIRA DOS SANTOS MARIANO e VALDECI DA SILVA, também qualificados nos autos, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.

Em razão do montante das penas, da gravidade concreta dos fatos e da reincidência de VINICIUS, não há se cogitar de conversão das penas privativas de liberdade em penas restritivas de direitos, a teor do art. 44 do CP, tampouco se viabiliza a concessão de sursis, à luz dos requisitos do art. 77 do CP.

Os requisitos para a manutenção da prisão preventiva de VINICIUS, adrede explicitados, não foram debelados, mas, sim, robustecidos, pela presente condenação, observando-se que a fixação do regime inicial fechado afasta qualquer violação ao postulado da proporcionalidade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Solução diversa assiste a JOSÉ GABRIEL, porque a fixação do regime inicial semiaberto não se compatibiliza com a manutenção da segregação provisória, impondo-se a sua imediata colocação em liberdade. O mesmo se diga, com mais razão, em relação aos demais corréus, ora absolvidos. Expeçam-se alvarás de soltura clausulados em relação a JOSÉ GABRIEL, WILLIAM, ANTONY e VALDECI.

Após o trânsito em julgado, suspendam-se os direitos políticos de VINICIUS e JOSÉ GABRIEL, nos termos do art. 15, III, da Constituição da República, oficiando-se aos respectivos Juízos Eleitorais.

Oficie-se ao IIRGD.

P.I.C.

São Paulo, 10 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA